

1500612-66.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... numeral 693, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Desembarcou da viatura, junto com o seu colega de farda, e passou a observar a referida residência e constatou cerca de cinco indivíduos chegarem até o portão da residência, em negociação típica do tráfico de drogas, e depois irem embora. Um dos indivíduos chegou à residência e a adentrou, qualificado posteriormente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500612-66.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500612-66.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055629/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 16457951 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO,

380/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2055629 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 380/21/505

- DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL PRESENTE DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

GABRIEL PRESENTE DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Consta da denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2021, às 22h00, na Rua Fernando Sanches, nº 693, Vila São Francisco, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu réu trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções – com massa de 2,28 gramas – de “maconha”, bem como 03 (três) porções – com massa de 11,72 gramas – de crack, ambas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 125) e o defensor nomeado apresentou defesa preliminar (fls. 130/131).

A decisão de fls. 132/133 recebeu a denúncia no dia 16 de novembro de 2021.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06, bem como a fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal, que se destina à apuração da responsabilidade do acusado GABRIEL PRESENTE DE LIMA, pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, conjugado com os laudos de constatação provisória de fls. 15/16 e 18/19 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 163/166 e 168/170.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Na fase extrajudicial, o policial militar Carlos Alexandre Cornélio declarou que há dias a polícia militar estava recebendo informações de que na residência localizada à Rua Fernando Sanches, nº 693, nesta cidade, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Dirigiu-se ao local na companhia de seu colega de farda e verificaram que várias pessoas iam até o portão da residência e faziam contato com um indivíduo, entregavam algo e recebiam algo em troca, como se estivessem comercializando algo. Realizaram a abordagem pessoal dos indivíduos que estavam na residência, sendo que com Pedro foi encontrada duas porções de “maconha”, as quais informou tê-las adquirido do réu pela quantia de R\$ 10,00, já com o réu, ao seu lado, foi encontrado uma sacola com três pedras brutas de “crack”, e cerca de sete porções embaladas de “maconha”. Quanto ao “crack”, o réu informou aos policiais que vendia a referida droga conforme era solicitado pelo usuário e que geralmente quebrava a pedra e a vendia solta. Já havia realizado várias vendas. A maconha também era destinada para a venda e confessou ter vendido duas porções de drogas a Pedro. Esclareceu que as drogas encontradas com o réu estavam ao seu lado no sofá, mas que o réu estava “praticamente sentado em cima delas”. Além das drogas, com o réu foi encontrada a quantia de R\$ 284,00. Na carteira de Pedro havia uma quantia em dinheiro, cerca de R\$ 122,00, e duas porções de “maconha”. Foram realizadas

buscas dentro da residência, mas nada de ilícito foi encontrado. A proprietária do imóvel estava no local, a qual informou ser namorada do réu e este reside na cidade de Chavantes. (fl. 03 - mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Carlos declarou que na data dos fatos recebeu uma denúncia que pela Rua Fernando Sanches, n.º 693, nesta cidade, estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Diante da denúncia, deslocou-se até o local na companhia do seu colega de farda. Desembarcou da viatura e ficou próximo a referida residência, observando vários indivíduos chegarem até o portão e logo em seguida irem embora. Em determinado momento, uma pessoa chegou ao local, fez o contato e entrou na residência. Com isso, junto com o policial Nascimento, foram até o portão da residência e por uma fresta conseguiram ver um indivíduo, depois qualificado como Pedro, conversando com Gabriel. Como também foi possível ver Pedro entregando a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) a Gabriel, o qual lhe entregou duas porções de "maconha". Pedro colocou as duas porções de "maconha" na carteira. O portão da residência estava aberto, assim, o depoente e o seu colega de farda adentraram o quintal da residência para abordar os indivíduos. Quando Gabriel se levantou de um sofá e deixou no sofá 07 (sete) porções de maconha que estavam embaladas separadamente e 03 (três) pedras de crack, sendo uma delas maior, ou seja, em estado bruto, bem como uma lâmina de "gillete". Com Gabriel também foi encontrada a quantia de R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais). Gabriel assumiu a propriedade das drogas encontradas, bem como informou residir em Chavantes e aquele local seria a residência de sua namorada. Já com Pedro, foi encontrada dentro de sua carteira duas porções de maconha e mais um valor em dinheiro, o qual não se recorda precisamente, seria cerca de "cento e poucos reais". Conversou com Pedro e ele informou ter ido ali para adquirir maconha. Diante da materialidade, foi dada voz de prisão a Gabriel. Não sabe dizer se Gabriel possui outras passagens pela polícia. Acredita que Pedro é irmão de Janaina, namorada de Gabriel e proprietária da residência. (fl. 183 - mídia audiovisual).

No mesmo sentido, na fase extrajudicial, o policial militar Fernando do Nascimento Oliveira declarou que a polícia militar estava recebendo há alguns dias denúncias de que na residência onde foram apreendidas as drogas com o réu Gabriel, estava ocorrendo a traficância. Dirigiu-se ao local na companhia de seu colega de farda, onde realizaram campana e perceberam uma frequência de indivíduos chegando ao local, entregando algo ao réu e recebendo algo em troca. Posteriormente, um indivíduo chegou ao local e o adentrou, sendo este identificado como Pedro, o qual é irmão da proprietária da residência. Aproximaram-se do portão da residência e avistaram o réu entregar algo a Pedro e este, por sua vez Pedro entregou ao réu uma nota de R\$ 10,00. O portão estava aberto, os policiais adentraram e realizaram a busca pessoal em Pedro e com ele foi encontrado duas porções de maconha e com o réu, o qual estava sentado em um sofá e ao seu lado, junto dele, havia uma sacola com substâncias entorpecentes, notas de dinheiro diversas e uma gilete. No interior da residência nada de ilícito foi encontrado. O réu confessou aos policiais que estava na traficância e que utilizava a gilete para cortar o "crack" para a venda. O réu reside no município de Chavantes. Já Pedro informou que não reside no local e que aquela casa é de sua irmã, Janaina, e que foi ao local para adquirir maconha com o réu. A residência é murada, mas o portão possui umas placas de metal, onde há algumas frestas. (fl. 02- mídia audiovisual).

Em Juízo, o policial militar Fernando declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento com o seu colega de farda pela Rua Fernando Sanches. Havia denúncias de que nesta rua, no numeral 693, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas. Desembarcou da viatura, junto com o seu colega de farda, e passou a observar a referida residência e constatou cerca de cinco indivíduos chegarem até o portão da residência, em negociação típica do tráfico de drogas, e depois irem embora. Um dos indivíduos chegou à residência e a adentrou, qualificado posteriormente como Pedro. Foi até o portão da residência e por uma fresta conseguiu observar Pedro pegando algo da mão de Gabriel, guardando em sua carteira e entregando o valor de R\$ 10,00 (dez reais) a Gabriel, o qual se sentou em um sofá. Nesse momento, o depoente e o seu colega adentraram a residência e se depararam com Gabriel sentado em um sofá e Pedro em pé. Ambos foram abordados. Quando Gabriel se levantou, deixou no sofá 07

(sete) porções de maconha e 03 (três) porções de “crack”, sendo uma ainda em estado bruto. Com Pedro foi encontrada duas porções de maconha dentro de sua carteira e a quantia de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois) reais. Com Gabriel, além da droga, também havia a quantia de R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) e uma “gillete”. Foi dada voz de prisão a Gabriel, o qual foi conduzido a delegacia juntamente com Pedro. O réu Gabriel ao ser indagado, respondeu residir na cidade de Chavantes e que aquela residência seria de sua namorada e que estaria ali para realizar a venda de drogas. Por sua vez, Pedro respondeu que havia comprado as duas porções de “maconha” com Gabriel. Além disso, informou que Pedro adentrou a residência por possuir um parentesco com a namorada de Gabriel. (fl. 183 – mídia audiovisual).

Na fase extrajudicial, Pedro Henrique Silva declarou que passou na residência de sua irmã, onde estava aguardando a chegada de um lanche, e se deparou com o réu no local, o qual informou que possuía maconha. O réu reside em Chavantes e as vezes vai na residência de sua irmã, acredita que eles “ficam”. Informou ser usuário de maconha e comprou duas porções de maconha do réu, pelo valor de R\$ 10,00, entregou o dinheiro a ele. Guardou as duas porções de maconha em sua carteira. Quando chegou a polícia militar e adentrou a residência, a testemunha estava na companhia do réu na área da residência. Na abordagem pessoal a polícia encontrou consigo as duas porções de maconha e com o réu, que estava sentado, encontrou ao seu lado um saquinho plástico, onde havia maconha e uma “crack”. Mas não sabe informar a quantidade, pois tudo foi muito rápido. Trabalha em uma marcenaria. Não sabe informar se sua irmã sabia que o réu estava com essas drogas, pois não reside com ela. (fl. 04 – mídia audiovisual).

Interrogado perante autoridade policial, o réu Gabriel Presente de Lima inicialmente informou que falaria apenas em Juízo, mas passou a indagar a autoridade policial sobre a quantidade de droga apreendida pelos policiais militares e ao tomar conhecimento que havia “sete porções pequenas de maconha e uma rocha maior de crack e outras pequenas de crack”, disse que estava apenas com a maconha e com uma porção pequena de “crack”, todas para uso próprio. Negou a traficância, bem como negou que estaria vendendo drogas a Pedro. A residência em que foi apreendido é da irmã de Pedro e frequenta o local, onde há umas “festinhas”. Negou que Pedro e sua irmã soubessem das drogas apreendidas e sobre o dinheiro encontrado, cerca de R\$ 265, informou ser fruto do seu trabalho. Quanto ao “crack” apreendido, informou que “os caras colocaram um pedaço de crack, só tinha um negocinho assim”, fez referência a um pedaço pequeno de droga mostrando o tamanho de sua unha da mão. Pegou as drogas na cidade de Ribeirão Claro/PR com uma menina, mas não soube declinar seu nome. (fl. 05 – mídia audiovisual).

Interrogado em Juízo, o réu negou ter praticado o crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. Na data dos fatos trabalhava com gesso e o seu patrão lhe deixou próximo à Rua Fernando Sanches, onde sua ex-namorada residia. Recebia R\$ 500,00 (quinhentos reais) por semana pelo seu trabalho e neste dia havia recebido tal valor. Inicialmente, antes de ir para a residência de sua ex-namorada, passou em uma adega e adquiriu duas caixas de cerveja e foi até a praça da Vila Musa, local conhecido como “biqueira”, e encontrou um “moleque” e pegou com ele 07 (sete) porções de maconha e 01 (um) pedaço de crack. Ao chegar na residência de sua ex-namorada, Janaína, havia vários parentes dela. Com isso, avisou Janaína que depois fumariam as drogas que ele havia adquirido. Afirmou ser usuário de drogas, bem como sua ex-namorada. Informou que Pedro já estava na residência de Janaína. Depois que os parentes de Janaína foram embora, Pedro permaneceu. Estava dichavando a maconha com o “crack” para fazer o consumo, quando os policiais militares chutaram o portão da residência e o quebraram. O portão estava trancado e a fresta era pequena, negou que fosse possível visualizar qualquer movimentação dentro da residência por meio da fresta. Os policiais entraram a residência e o réu já assumiu a propriedade das drogas, bem como informou que o dinheiro que possuía era fruto de seu trabalho como gesseiro e que poderia comprovar tal afirmação. Na delegacia ficou em uma cela separado de Pedro. Depois que Pedro deu o seu depoimento, bem como os policiais militares, foi chamado para depor por policiais civis. A ele foi apresentado pelos policiais civis as sete porções de maconha e ainda três porções de “crack”, contudo

nega que possuísse três porções de "crack". Afirmar que possuía apenas uma porção de "crack". Quando a porção maior de "crack" nega que seja sua. Assumiu que o dinheiro encontrado também era seu. Quanto a droga encontrada com Pedro, disse que depois que os policiais lhe abordaram e lhe deram voz de prisão foi pedido a Pedro um documento de identificação, assim, Pedro pegou sua carteira e nesse momento foi encontrada apenas uma porção de maconha com Pedro. Depois os policiais indagaram Pedro, falando que ele teria comprado aquela droga com Gabriel, Pedro ficou nervoso e disse ter adquirido a droga com Gabriel, mas este fato não é verdadeiro. Não sabia que Pedro já tinha uma porção de maconha, pois das drogas que adquiriu era para que Pedro e Janaína também fizessem o uso. Voltou a trabalhar depois que foi solto na audiência de custódia. Sempre foi viciado em drogas e há três meses deixou de fazer o uso de "crack". Indagado quanto ao depoimento de Pedro, na fase policial, o qual informou ter adquirido duas porções de maconha com o réu pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais), respondeu que essa informação não é verdadeira e que Pedro disse isso porque foi "induzido" pelos policiais, ainda na residência de Janaína, a falar isso. Não teve mais contato com Pedro e Janaína pediu desculpas ao réu, pois "ela sabe da verdade". Depois se afastou também de Janaína. Negou que houvesse uma "gillete" junto com ele no sofá, apenas no banheiro e que os policiais "reviraram" a casa inteira. A maconha que comprou a dichavava na mão, bem como a pedra de "crack". Possui vinte e dois anos e nunca foi preso anteriormente. Porém, quando adolescente cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida. Possui cerca de quatro atos infracionais. Está trabalhando com carteira registrada e recebe cerca de R\$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). (fl. 183 - mídia audiovisual).

Estas foram, em resumo, as provas produzidas em cenário judicial, observadas as regras pertinentes ao devido processo legal, em especial do contraditório e da ampla defesa.

A negativa do acusado está isolada nos autos. A traficância está bem evidenciada, cristalina.

Os policiais militares narraram que em patrulhamento pela Rua Fernando Sanches e que havia denúncias de que na residência com numeral 693 havia a prática de tráfico de drogas. No local, verificaram que indivíduos chegavam no portão, faziam contato com indivíduo e saíam, em atitude típica de tráfico. Ainda, conseguiram visualizar o réu entregar duas porções de "maconha" para Pedro que, por sua vez, entregou para o réu uma cédula de R\$ 10,00 (dez reais). Fizeram a abordagem dos indivíduos e com o réu localizaram 07 (sete) porções de "maconha", 03 (três) pedras brutas de "crack" e uma lâmina, além da quantia de R\$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais). Já com Pedro localizaram duas porções de maconha e a quantia de R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais). Na ocasião o réu admitiu o tráfico de drogas. Como se vê, os relatos prestados, tanto em juízo quanto na fase policial, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer elementos que permitissem a ilação de que as testemunhas estariam animadas do propósito de incriminar indevidamente o acusado.

Com efeito, a droga apreendida, que o réu trazia consigo, destinava-se à venda, o que se extrai das circunstâncias do caso concreto, vale dizer, pela quantidade, natureza e forma que acondicionada a droga, sendo apreendido com o réu 07 (sete) porções de maconha - com massa de 2,28 gramas - e 03 (três) pedras de "crack" - com massa de 11,72 gramas - sendo 02 já embaladas e prontas para a venda e 01 em estado bruto, e uma lâmina de barbear, conforme se extrai do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudos de constatação provisória de fls. 14/16 e 17/19, conjugado com laudo definitivo de entorpecentes de fls. 162/166 e 167/170; bem como pelos relatos dos policiais militares, de que havia informações de que a residência em que o réu estava era um local de venda de drogas e que narraram que visualizaram o réu fazer transações de tráfico de entorpecentes.

Vale recordar, que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, terem

depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos.” (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 01.07.2016) “TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais. Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação. Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido. Recurso improvido.” (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01.04.2015).

Anoto que o valor do depoimento testemunhal dos servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

“A prova policial só deve desprezada, afastada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando totalmente ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo através de regular instrução. Havendo, porém, prova produzida no contraditório, ainda que menos consistente, pode e deve aquela ser considerada e chamada para em conjunto com esta, compor quadro probante suficientemente nítido e preciso (RJTERGS 150/143-3)” (Julio Frabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., p. 89, Atlas, 2000).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido” (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações

não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Assim, a versão do acusado de que os policiais teriam forjado sua prisão e conduta delituosa é mendaz, evasiva e inverossímil, além de não ter sido demonstrada pela Defesa por qualquer meio de prova, que, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Sob tais fundamentos, entre a versão dos policiais militares e a versão do réu, privilegia-se a dos primeiros. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS ROBUSTAS CONTRA O ACUSADO. PLEITO DE FLAGRANTE FORJADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. ARGUMENTO DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS NO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. PRESENÇA NOS AUTOS DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A condenação do acusado está satisfatoriamente fundamentada nas provas juntadas aos autos, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo Pericial Toxicológico e no depoimento do policial responsável pela prisão do apelante. 2. Não há nos autos qualquer prova de que o flagrante foi forjado pelos policiais, nem menção do motivo ou interesse que os policiais tivessem para produzir provas contra um inocente. Dessa forma, o argumento não merece prosperar. 3. O testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório do depoimento de outras testemunhas, haja vista que submetido às mesmas regras referentes ao juramento e à pena de falso testemunho, além de também ser colhido sob o crivo do contraditório. Assim, como qualquer outro meio de prova, o depoimento de policiais é, portanto, idôneo para fundamentar a condenação. Precedentes do STF e STJ.” (TJSP – Processo: APL 174120078171360PE000001741.2007.8.17.1360. Relator(a): Marco Antônio Cabral Maggi. Julgamento: 23/09/2011. Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal.).

Quanto às denúncias que recaem sobre o réu, no sentido de que estaria praticando o tráfico de entorpecentes, é certo que isoladamente denúncias anônimas não possuem o condão de condenar alguém, mas aliadas a outros elementos probatórios constituem indícios concretos da prática delitiva, como é o caso dos autos, na qual os policiais visualizaram o réu comercializando drogas e encontraram junto ao acusado 07 (sete) porções de maconha, com massa líquida de 2,28 gramas, e 03 (três) pedras de “crack”, com massa líquida de 11,72 gramas, parte fracionada e parte em estado bruto, além de lâmina de barbear e dinheiro sem comprovação de origem lícita.

Como se observa, ainda que as denúncias anônimas sejam provas indiciárias, quando corroboradas por outras provas dos autos é elemento valioso na análise da adequação típica do tráfico de drogas. Sobre o assunto:

“Tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público Pedido de Condenação do corréu Thiago. Acolhido Autoria e materialidade comprovadas para ambos os réus Robusto conjunto probatório - Seguros e insuspeitos relatos dos policiais militares que confirmaram: a denúncia anônima dando conta da prática do tráfico de drogas praticado por dois indivíduos, passando, inclusive, as características deles; bem como a confissão informal dos dois acusados - Réu que foi visto dispensando quantia em dinheiro em notas amassadas - Atitude comum em coautoria na venda espúria, onde um agente é responsável pelas drogas e o outro pelo dinheiro. Pedido da acusação para aumento da pena base - Possibilidade - Quantidade e diversidade de drogas que justificam o acréscimo nesta etapa. Pedido da acusação para afastar a confissão do corréu Vanderson - Possibilidade - Confissão parcial feita com o intuito de excluir a culpabilidade de seu comparsa, e não com o escopo de auxiliar na resolução da ação criminal - Impossibilidade de concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas - Réus reincidentes - Regime fechado é medida necessária - Dado provimento ao recurso ministerial.” (Apelação Criminal nº 1501052-47.2018.8.26.0544; 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Freitas Filho, julgamento em 09.10.2019) (destaquei).

Assim, as denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia

e, quando são confirmadas com elementos concretos nos autos, merecem guarida para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assumira sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam. Sobre a destinação da droga, é de se destacar que foram apreendidas com o réu 07 (sete) porções de maconha – com massa de 2,28 gramas – e 03 (três) pedras de “crack” – com massa de 11,72 gramas – parte já embaladas e prontas para a venda e partes em estado bruto, o que conduz à segura conclusão de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, pois é cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, é repartida em porções individuais para facilitar o comércio a terceiros.

Nesse sentido:

“Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas” (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

“Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papéletes, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores.” (TJRJ - rel. PAULO GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Nesse interim, a literatura jurídica revelou que usualmente cada porção de maconha equivale a 0,6 grama (STJRHC nº 37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz -j. 22.10.2013); cada porção de cocaína equivale a cerca de 0,25 grama (STF HC nº 111.247/MG 2ª Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski - j. 27.03.2012), cada porção de crack equivale a cerca de 0,1 grama (STFHC nº 114.390/RS 1ª Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013).

Com base nestes dados, conclui-se que a quantidade de “crack” apreendida (11,72 g) seria suficiente para produzir aproximadamente 117,2 porções individualizadas da droga. Já em relação a quantidade de maconha apreendida (2,28 g) seria o suficiente para produzir aproximadamente 3,8 porções individualizadas da droga.

Ainda, realce-se “que, consoante a literatura médica e a jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida (7,97g) representa, pelo menos, 398 porções “insuportáveis”, ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5ª edição, Editora Saraiva, 2.004, nº. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1ª edição, 1.988, nº. 42, pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal nº. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil comércio” (TJSP - Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator Desembargador COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Ainda, pontuo que se o réu é realmente usuário de drogas, tal circunstância não exclui sua condição de traficante. Ao contrário, reforça-a, pois é comum que o usuário venda drogas para manter seu vício. Aliás, infelizmente esse não é um caminho incomum, ou seja, a prática cotidiana comprova que no mais das vezes o usuário segue o caminho do vício até não poder mantê-lo às suas próprias expensas, e então passa a vender drogas para mantê-lo.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“TÓXICOS Tráfico Alegação de ser o acusado usuário de entorpecentes. Irrelevância. Hipótese em que uma conduta não exclui a outra, sendo comum o tráfico entre dependentes ou usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo Recurso improvido.” (TJSP. Apelação Criminal n. 1.167.864.3/4 Ibitinga 5ª Câmara Criminal, Relator: Juvenal Duarte 15.05.08 M.V. Voto n. 2.478).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu ser usuário não o desqualifica como traficante.

Portanto, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.



Provas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu GABRIEL PRESENTE DE LIMA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Passo à aplicação de sua pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em análise às diretrizes previstas nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, verifico que o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, já que traficava maconha e "crack", droga conhecida por sua natureza altamente viciante, destrutiva e nociva à saúde humana. Assim, "Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes" (STJ, HC 187330/MG, Relator Ministro GILSON DIPP, julgamento em 03.05.2011).

Sobre a nocividade da cocaína na forma de "crack", transcrevo trecho de julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Oportuno destacar que, em matéria jornalística veiculada na Folha de S. Paulo do dia 31.5.2015, noticiou-se estudo indicativo de que ao menos 1.685 pessoas morreram no Est. de S. Paulo em 2013 após terem consumido cocaína, uma média de cinco óbitos diários. E, "Segundo especialistas, o crack é 'cinco vezes mais potente que a própria cocaína e produz dependência com muita facilidade e quase imediatamente após seu primeiro ou segundo uso (...) Os efeitos produzidos ao usuário são basicamente iguais ao da cocaína, porém muito mais intensos (...)'" (João Gaspar Rodrigues, Tóxicos, Bookseller, 2001, p. 63)" (RT, 838/571). Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade ao organismo humano, tornando o usuário, em curto - período de tempo, "escravo do desejo de consumir o entorpecente". Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack (...) possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. Toxicologia Forense cit., cap. V, nº 1.3.1, pág. 136)" (TJSP. Apelação Criminal nº 0004647-51.2018.8.26.0408. 2ª Câmara de Direito Criminal. Relator COSTABILE E SOLIMENE. Julgamento em 05.08.2019).

Sem dúvida, não se pode negar a nocividade da cocaína em pedra, que apresenta maior lesividade.

Portanto, essa circunstância (natureza) autoriza a exasperação da pena em face da maior reprovabilidade da conduta, na esteira do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a quantidade e natureza da droga como circunstância preponderante na fixação da pena base.

Nesse sentido:

1. A natureza da droga apreendida - cocaína, dotada de alto poder viciante - constitui fundamento idôneo a ensejar a exasperação da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (STJ, HC 338379/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 06.12.2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz

deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Ag regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 476995 / SC, 5ª Turma, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento em 03.05.2019.)

"O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12).

"No crime de tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base, amparada no art. 59 do Código penal, uma

vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (STJ, 5ª T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5ª Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.).

Assim, em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas (natureza da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), retornando a pena ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Saliento que o caso concreto não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa. Com efeito, o réu, que por ocasião de sua prisão contava com 20 anos, respondeu a quatro processos de apuração de ato infracional (fl.35/36), e conforme relatou em seu interrogatório, cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida e ficou internado por atos infracionais relacionados a drogas, inclusive análogo ao tráfico de drogas. Referida dedicação do réu ao crime também é corroborada pela narrativa dos policiais de que havia informações de que na residência onde o réu foi preso em flagrante era praticado o tráfico de drogas, evidenciando que não se trata de uma traficante de primeira viagem (o que ensejaria a aplicação do redutor), e permite concluir que fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, estando inserida no espúrio comércio há algum tempo.

Vale rememorar o texto legal:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput em o §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (destaquei).

Nesse sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA E PETRECHOS) – O RECURSO MINISTERIAL OBJETIVA APENAS QUE SEJA FIXADO O REGIME FECHADO – COM RAZÃO – SEQUER ERA CASO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE, POIS DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO RÉU AO TRÁFICO, POIS JÁ TEVE PASSAGEM PELO JUÍZO DA INFÂNCIA POR CONDUCTA ANÁLOGA – TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM – TAMBÉM HOUVE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO, MAS QUEDOU-SE INERTE O MINISTÉRIO PÚBLICO – A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS, DE RIGOR O REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FIXAR REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUANDO ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA." (Apelação Criminal nº 0000013-19.2018.8.26.0438, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, julgamento em 27.08.2019) (destaquei)

Dada a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos; a quantidade de pena aplicada; a natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e "crack"), sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, concretamente considerada, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o fechado.

E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua equiparada hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício.

Inviável, igualmente, a aplicação do sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu GABRIEL PRESENTE DE LIMA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a

cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu respondeu ao processo em liberdade e assim poderá apelar.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo das execuções criminais; (b) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (c) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos. Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos, tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, e por considerá-los imprestáveis, determino o seu encaminhamento para imediata destruição após o trânsito em julgado.

Considerando o que dos autos consta, deixo de condenar o acusado em custas processuais.

Ao Dr. Defensor nomeado, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Ourinhos, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA